

1500555-75.2021.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... não se pode esquecer que, no tocante ao tráfico de drogas, as pessoas são resistentes em fornecer informações e se identificar, com medo de represálias, bem como que o tráfico de drogas exerce forte vigilância nas proximidades dos pontos de venda, bem como locais onde as drogas se encontram escondidas, o que dificulta, sobremaneira, a campana nos referidos locais, restando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500555-75.2021.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500555-75.2021.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FÁBIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES JÚNIOR e outros

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

FÁBIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 6h45min, na Rua Marília, n. 137, na cidade de Vera Cruz, nesta comarca, guardava, para fins de tráfico, 8 (oito) microtubos contendo crack, com peso líquido de 0,61 g (seiscentos e dez miligramas), 1 (um) tablete de maconha, com peso líquido de 21,62 g (vinte e um gramas, seiscentos e vinte miligramas) e 1 (um) tijolo de crack, com peso líquido de 199,53 g (cento e noventa e nove gramas e quinhentos e trinta miligramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudos acostados aos autos, além da quantia de R\$ 5.389,75 (cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), 3 (três) aparelhos celulares e 2 (duas) motocicletas.

Preso em flagrante delito, houve a conversão em prisão preventiva (fls. 70/74). O réu foi notificado (fls. 186) e apresentou defesa prévia (fls. 150/153). A denúncia

foi recebida em 14/3/2022 (fls. 169/171). O réu foi citado (fls. 233). Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 12/4/2022, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa (fls. 237/238 e mídia). Em continuação, na audiência realizada em 31/5/2022, foi ouvida uma testemunha de defesa e o réu foi interrogado (fls. 247/248 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, pugnou pela fixação da pena acima do mínimo legal na primeira fase, em função da natureza dos entorpecentes, pela majoração da pena na segunda fase, ante a reincidência, apontando para a ausência de causas de aumento e diminuição de pena na terceira fase. Por fim, requereu a fixação do regime inicial fechado e a decretação do perdimento dos bens e valores apreendidos (fls. 252/263 e 533).

A Defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, a nulidade da medida de interceptação telefônica e a consequente ilegalidade do mandado de busca e apreensão domiciliar, com a consequente absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, III, do CPP. No mérito, ante a ausência de provas suficientes à condenação, pleiteou a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, com a consequente desclassificação da conduta atribuída a ele para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Em caso de condenação, postulou, na primeira fase, a fixação da pena em seu patamar mínimo legal; na segunda fase, ante a reincidência, a exasperação da pena em 1/8; e, na terceira fase, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da condenação anterior decorrer de delito de menor potencial ofensivo. Requereu, ainda, a fixação de regime prisional diverso do fechado, além de observação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. Por fim, pugnou pela concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 536/612).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da interceptação telefônica e a consequente ilegalidade do mandado de busca e apreensão domiciliar. Se não, vejamos.

O afastamento do sigilo telefônico, telemático e de dados dos aparelhos celulares somente foi determinado após diversas outras diligências que culminaram na identificação do acusado e porque havia indícios razoáveis de autoria do delito de tráfico de drogas, além das provas não poderem ser obtidas por outros meios, conforme bem delineado na representação da D. Autoridade Policial e no relatório de investigação de fls. 283/290 e 291/295, respectivamente.

Cumprе salientar que no início da fase investigatória, na maioria das vezes, não se tem ainda um quadro nítido sobre os acontecimentos, razão pela qual não se pode desprezar a realização da interceptação como importante prova para a persecução penal, sem prejuízo das demais provas.

Outrossim, não se pode esquecer que, no tocante ao tráfico de drogas, as pessoas são resistentes em fornecer informações e se identificar, com medo de represálias, bem como que o tráfico de drogas exerce forte vigilância nas proximidades dos pontos de venda, bem como locais onde as drogas se encontram escondidas, o que dificulta, sobremaneira, a campana nos referidos locais, restando demonstrada a necessidade da interceptação telefônica.

A renovação da interceptação telefônica por prazo superior ao previsto no art. 5º da Lei nº 9.296/96 se deu observando o princípio da razoabilidade e diante da comprovação da necessidade da medida para a investigação, em decisões fundamentadas

(352/354, 401/403 e 460/462), mormente em virtude de se tratar de suposta organização criminoso voltada para o tráfico de drogas. No mesmo sentido, recente decisão do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012).

2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial.

3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022.

4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto".

(Recurso Extraordinário 625.263/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, j. em 17/3/2022).

Logo, lícita e regular a interceptação telefônica e, por consequência, a busca e apreensão domiciliar.

Quanto ao mérito, a existência material dos crimes tipificados na denúncia, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelas provas colhidas durante a instrução, tais como o auto de prisão em flagrante de fls. 5/6, boletim de ocorrência de fls. 7/11, auto de exibição e apreensão de fls. 14/16, fotografias de fls. 33/35 e 39/40, laudos de constatação provisória de fls. 43/45 e 46/48, relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 129/132), laudos químicos-toxicológicos de fls. 187/191 e 614/617, estes atestando a natureza das substâncias apreendidas (Tetrahidrocannabinol - THC e Cocaína), cópia dos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico - processo nº 0007657-96.2021.8.26.0344 (fls. 282/526), cópia do procedimento cautelar de Busca e Apreensão - processo nº 1513262-46.2021.8.26.0344 (fls. 618/660), e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Diogo Arevalo Kawaguti e Marcos da Silva Machado, policiais civis, declararam que, no curso de uma investigação sobre uma organização criminoso que praticava o tráfico de drogas em Vera Cruz/SP, denominada "Operação Hades", requereram o deferimento de uma interceptação telefônica na qual um dos alvos era o réu. Diante dos indícios de que ele realmente estava traficando drogas, solicitaram um mandado de busca domiciliar para vistoriar as casas da mãe e da avó do réu. Na casa de sua avó foram encontrados aproximadamente R\$5.000,00 e 8 "pinos" crack. Na casa de sua mãe, local onde ele foi preso, havia uma grande quantidade de crack e de maconha. Foram apreendidos motocicletas e celulares. Restou claro pelas informações contidas nos celulares que todos os bens do réu provinham do tráfico de drogas, pois ele era desempregado e não tinha outras rendas lícitas. Inclusive, a mãe do réu, após a prisão dele, teve que pedir dinheiro emprestado para se sustentar.

A informante Maria de Lourdes de Souza Vieira declarou que na data dos fatos estava sozinha na sua casa quando os policiais chegaram e perguntaram pelo seu neto. Ela informou que ele não tinha dormido no local. Os policiais realizaram a busca e não encontraram nenhum entorpecente. Apenas encontraram no quarto, dentro de um guarda-roupas, o dinheiro que ela guardou, decorrente de sua aposentadoria e de algumas mercadorias que ela vende na frente da sua casa. Uma das motos pertencia a um rapaz que deixou no local porque havia quebrado. A outra motocicleta foi financiada pela informante para o réu.

A testemunha de defesa Rosilene Balbino dos Santos declarou ter tomado conhecimento que o réu é usuário de drogas e que seus familiares já tiveram muito trabalho para lidar com a questão. Contudo, nunca escutou que ele seria traficante de drogas. Sabe que a avó do réu vende alguns produtos na frente da sua casa.

A testemunha de defesa Matheus Henrique de Souza Vieira dos Santos declarou que é primo do réu e sabe que ele é usuário de drogas. Inclusive, suspeita que ele tenha subtraído bens dele para trocar por entorpecentes. Nunca escutou pela cidade que ele seria traficante. A avó tinha uma distribuidora de cerveja em sua casa. O dinheiro que foi apreendido na casa dela era para ela repor estoque. O réu trabalhava no pesqueiro da mãe da testemunha, nos finais de semana, ganhando R\$50,00 por dia. Uma das motos encontrada na casa da avó do réu pertencia a um rapaz que deixou no local porque havia quebrado. A outra motocicleta foi financiada pela avó para o réu. A avó e mãe do réu o sustentavam.

A testemunha de defesa Felipe dos Santos declarou que estudou muito tempo com o réu. Contudo, se afastou dele, diante do envolvimento com o uso de drogas. Nunca escutou na cidade que ele era traficante de drogas, mas apenas um usuário.

O réu Fábio Henrique de Oliveira Marques Júnior declarou que na data dos fatos estava na casa da sua mãe quando os policiais apareceram e encontraram certa quantidade de droga, que era para o seu consumo pessoal. Ele comprava porções maiores de entorpecente porque tinha medo de ser confundido com traficante de drogas nos pontos de venda. O dinheiro encontrado na casa da sua avó pertencia a ela, sendo que ele sequer tinha conhecimento da sua existência. Uma das motos encontradas era sua e foi financiada pela sua avó, que é aposentada e tem um pequeno comércio na sua casa. A outra pertencia a um amigo seu, que deixou a moto no local porque ela quebrou.

Em que pesem os argumentos defensivos, há prova suficiente para a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Pelo que se infere dos autos, foi desencadeada pela Delegacia de Polícia de Vera Cruz/SP a denominada "Operação Hades", com o objetivo de apurar crime de associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas.

Conforme relatório realizado pela Equipe da Polícia Civil nos autos nº 0007657-96.2021.8.26.0344, da 2ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 512/522), através da interceptação telefônica foi possível constatar que a referida organização criminosa era chefiada pelo acusado FÁBIO, vulgo "Binho" ou "Quero Júnior". Os diálogos interceptados revelaram que os cargos eram bem definidos, sendo que o acusado comprava as drogas de Andrade Graciano da Silva (preso recentemente em operação desenvolvida pelo Centro de Inteligência Policial de Marília) e Grazielle avisava-o da presença dos policiais, prejudicando as campanhas e as operações para o combate ao tráfico de drogas. Havia os "vapores", que transportavam as drogas, apetrechos e dinheiro para o traficante, os traficantes menores, que comercializavam a droga em locais fixos e recebiam remuneração pré-estabelecida e os "moleques", que tinham a função de guardar as drogas. Foi constatado, ainda, que o acusado usava a casa da avó e da mãe como depósito de dinheiro ou para embalar as drogas que eram distribuídas nas biqueiras.

A interceptação telefônica viabilizou a diligência de busca e apreensão, deferida nos autos nº 1513262-46.2021.8.26.0344, da 2ª Vara Criminal desta Comarca (fls. 618/660), e que culminou na apreensão de drogas na casa da mãe do acusado e de drogas e dinheiro na casa da avó dele, bem como na prisão em flagrante do acusado.

Oportuno pontuar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei de Drogas é crime de natureza múltipla e a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico.

Nos termos do disposto no artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, existe a convergência de algumas situações indicativas do tráfico de entorpecentes, tais como: a) a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidas no total, ou seja, 8 (oito) microtubos de crack, pesando 0,61 gramas, 1 (um) tablete de maconha, pesando 21,62 gramas, e 1 (um) tijolo de crack, pesando 199,53 gramas; b) a vultosa soma em dinheiro, em notas e moedas diversificadas e sem comprovação de origem lícita; c) o conteúdo dos diálogos travados entre o réu e os interlocutores, objeto da interceptação telefônica, destacando sobremaneira a função do acusado como chefe da organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Ao contrário do alegado pela defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos tanto no que concerne aos diálogos interceptados quanto no que diz respeito às buscas e apreensões efetivadas. Além disso, a prova oral está em consonância com a prova pericial que instrui os autos, inexistindo qualquer discrepância acerca da dinâmica dos fatos e revelando, sem qualquer dúvida, a ocorrência do comércio de drogas, bem como a autoria do crime.

Outrossim, o relatório acerca dos diálogos interceptados é mais do que suficiente para caracterizar a traficância e sua autoria.

Aliás, a convergência dos diálogos interceptados com a busca e apreensão resultou na apreensão dos entorpecentes e de vultosa quantia em dinheiro. E, como visto nos referidos diálogos, é nítido que o acusado aparece em diversas situações: responsável pelo recebimento das drogas, pelo revezamento dos vendedores na “biqueira”, por repor os entorpecentes na “biqueira”, bem como pelo fracionamento da droga, quando necessário.

Em que pese a combativa Defesa argumentar que a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), restou amplamente demonstrado que a droga destinava-se ao tráfico ilícito de drogas. Além de não ter feito prova de que seria para o uso do réu, mesmo que ele seja usuário, tal fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros.

Além do mais, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida não é compatível com a condição de usuário.

Portanto, denota-se pelas provas coligidas que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O pedido de restituição dos bens e valores apreendidos não merece acolhida. Isso porque a situação é regida pelo artigo 91, II, “b”, do Código Penal, que prevê o perdimento em favor da União do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido com a prática do delito, bem como pela Lei de Drogas, que prevê em seus artigos 61 a 63 o perdimento em favor da União de bens e veículos empregados como instrumento do crime de tráfico.

Embora a avó do acusado, a informante Maria de Lourdes de Souza Vieira, tenha dito em Juízo que o dinheiro apreendido lhe pertencia, pois era fruto de sua aposentadoria e de algumas mercadorias que vende na frente da sua casa, tal alegação não convence. Com se vê a fls. 520/521, houve uma ligação telefônica no dia 21/12/2021, na qual o acusado pede para sua avó pegar R\$100,00 (cem reais) no quarto dele porque a “Tia Elaine” ia passar pra pegar. Restou demonstrado, portanto, que o dinheiro apreendido na casa da informante Maria de Lourdes, na verdade, pertencia ao acusado.

Quanto às motocicletas apreendidas, a versão de que uma delas pertencia a um rapaz que a havia deixado na casa da genitora do acusado porque estava quebrada não encontra respaldo probatório nos autos.

Conquanto tenha havido pedido de restituição da motocicleta HONDA/NX 4 FALCON, placa CTE9457, cor cinza, chassis sob nº 9C2ND07002R004562, ao suposto proprietário Luis Vitor da Silva (processo dependente nº 0004272-09.2022.8.26.0344), como já explanado na decisão que indeferiu o pedido, o documento indicando a compra da motocicleta pelo requerente, por si só, não é suficiente para impedir a decretação do perdimento do bem, pois a transferência de propriedade de bens móveis decorrem de mera tradição, situação esta de difícil comprovação. E, ainda, não há justificativa plausível para que a moto estivesse na casa da genitora do réu.

Por sua vez, a alegação de que o financiamento da outra motocicleta seria pago pela avó do acusado também não prospera, haja vista ela mesma ter mencionado em Juízo que vendia mercadorias na frente da sua casa justamente porque o valor recebido a título de aposentadoria e pensão não era suficiente para seu sustento, uma vez que havia feito empréstimos consignados. Aliás, o acusado não exercia atividade lícita

remunerada de forma regular, restando evidente que o financiamento seria pago com os rendimentos do tráfico de drogas. Além disso, pelos elementos amealhados nos autos, verifica-se que o acusado utilizava-se das motocicletas como instrumento para a prática do comércio ilícito de drogas. Conforme se vê dos diversos diálogos constantes no relatório da Polícia Civil (fls. 512/522), o acusado tinha que se deslocar com frequência de um local a outro para repor os entorpecentes nas "biqueiras", não sendo crível que o fazia a pé, tendo as motos na garagem da casa da genitora.

Desta forma, está claro que o réu se valeu tanto do veículo, quanto dos aparelhos celulares para a consecução do delito, sendo de rigor o indeferimento do pedido. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO ILEGAL A DADOS DE TELEFONE CELULAR. IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE, CONDENÇÃO AMPARADA EM PROVAS DIVERSAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVIABILIDADE, DIANTE DA CONCLUSÃO DE QUE O BEM FORA UTILIZADO NA CONSECUÇÃO DO DELITO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no Recurso Especial nº 1.803.339 – DF, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgamento 7/5/2019).

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pedido de expedição de contramandado de prisão. Apelante que responde preso preventivamente desde o flagrante. Inexistência de alteração fática que denote necessidade de soltura depois da condenação e da presente confirmação. No mérito, pretendida redução das penas pela confissão e primariedade. Impossibilidade. Apelante que não confessou o delito. Primariedade e bons antecedentes que já pesaram favoravelmente na dosimetria das penas. Desclassificação para a forma privilegiada inviável. Transporte interestadual de mais de 500kg de maconha, mediante paga, em caminhão de sua propriedade. Incompatibilidade da conduta com a figura do pequeno e eventual traficante. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado necessário à luz da gravidade em concreto do delito. Perdimento do veículo confirmado, pois empregado como instrumento do crime. Apelo improvido. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 1501853-95.2020.8.26.0542, 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Otávio de Almeida Toledo, julgamento 1º/4/2021).

Comprovadas, assim, a materialidade e autoria do delito descrito na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6, em razão do réu ser reincidente (processo nº 1502268-27.2019.8.26.0344 - trânsito em julgado em 1/3/2021 - fls. 50), totalizando uma pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há incidência de atenuantes.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da

Lei nº 11.343/06, tendo em vista a reincidência do réu (fls. 50). Ademais, restou evidenciado que o réu não exerce atividade remunerada lícita de forma constante e os diálogos extraídos do aparelho celular do acusado revelam, no mínimo, dedicação a atividade criminosa.

Desta forma, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu FÁBIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade do acusado deve ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência e da gravidade do delito, equiparado a hediondo.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da reincidência e da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com entorpecentes altamente nocivos, de nefasta repercussão social (fls. 70/74), que foi mantida posteriormente (fls. 141/142 e 170), o que fez com que permanecesse encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, decreto a perda dos bens apreendidos, consistentes no numerário (depósito

judicial de fls. 127/128), nos aparelhos celulares e nas motocicletas constantes no auto de exibição/apreensão de fls. 14/16, em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, bem como a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, oficiando-se, após o trânsito em julgado.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o expresse permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA